

1500097-29.2021.8.26.0538

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME MARTINS DAMINI

Comarca: Santa Cruz das Palmeiras

Foro: Foro de Santa Cruz das Palmeiras

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 04/10/2022

... cidade, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, avistaram um sujeito identificado com EMERSON LUAN BORGES em atitude suspeita, ou seja, vislumbraram o indiciado entregar algo para uma mulher e receber dinheiro em troca; EMERSON é muito conhecido, nos meios policiais, pelo tráfico de entorpecentes e por esse motivo, imediatamente, abordaram EMERSON e a citada mulher, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Cruz das Palmeiras

Vara Única

Avenida do Café, nº 665, Centro, Santa Cruz Das Palmeiras - 13650-000 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Processo nº:

1500097-29.2021.8.26.0538

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2066554/2021, 16665729, 256/21/210, 2066554

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EMERSON LUAN BORGES

Ao(s) 04 de outubro de 2022, às 16 horas e 15 minutos, nesta cidade e Comarca de Santa Cruz das Palmeiras, sendo realizada, por meio virtual, via videoconferência criada no software Microsoft Teams, sob a presidência do(a) MM(a). Juiz(a) de Direito, Dr(a). GUILHERME MARTINS DAMINI, comigo, Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe.

Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, estiveram presentes na teleaudiência:

O(A) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). SERGIO HENRIQUE MARINO, DD(a). Promotor(a) de Justiça; A(O)(s) ré(u)(s) EMERSON LUAN BORGES, acompanhado(a)(s) de seu(s) Defensor(es)(a) (s) constituído(a)(s) Dr(es)(a)(s). Eduardo Rodrigues Azevedo OAB 169779/SP; A(s) testemunha(s) de comuns Marcio Costa Rodrigues e Lucas Francisquelli Gonçalo.

Após, antes do início dos trabalhos, o(a)(s) advogado(a)(s) de Defesa não solicitou(ram) comunicação privada com a(o)(s) ré(u)(s), em virtude de ter havido conversa prévia em lugar diverso e/ou ausência da(o)(s) ré(u)(s) na audiência virtual. Pelo Ministério Público, nada foi requerido.

Iniciados os trabalhos, pelo(a) MM(a). Juiz foi dito: "Nos termos da resolução 465 de 2022, do Conselho Nacional de Justiça, zelando pela adequada identificação e vestimenta que a solenidade requer, alerta ao(a)(s) Advogado(a)(s) e o(s) membro(s) da Defensoria Pública e do Ministério Público da necessidade de utilização de terno

ou toga, permanecendo com a câmera ligada, em condições satisfatórias e em local adequado durante toda sessão.".

Após, pelo(a) MM(a). Juiz(a), foi(ram) colhido(s) o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) Marcio Costa Rodrigues. Pelo Ministério Público e pela Defesa foi requerido a desistência na oitiva da testemunha e Lucas Francisquelli Gonçalo, sendo esta desistência homologada pelo MM(a). Juiz(a).

Em seguida, indagado pelo(a) MM(a). Juiz(a) se gostaria de entrevistar-se, novamente, com a(o)(s) ré(u)(s) antes do(s) interrogatório(s), o(a)(s) advogado(a)(s) de Defesa absteve-se da entrevista. Sendo assim, pelo(a) MM(a). Juiz(a), foi(ram) feito(s) o(s) interrogatório(s), em separado, se for o caso, da(o)(s) ré(u)(s) EMERSON LUAN BORGES.

O(s) depoimento(s) foi(ram) gravado(s) pelo sistema Microsoft Teams, informando-se os presentes sobre as gravações, com os tempos de gravação, de cada depoimento presente neste termo, indicados no formato (Horas:Minutos:Segundos) e/ou indicados por vídeos próprios na página dos autos dedicada à mídia desta audiência.

Ao final, pelas partes, foi dito que não havia requerimentos de diligências a serem apresentados e/ou provas a serem produzidas. Sendo assim, deliberou o(a) MM(a). Juiz(a): "Vistos. Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução e determino às partes que apresentem suas alegações finais.". Dada a palavra ao Ministério Público e a Defesa, suas alegações finais orais foram gravadas pelo sistema Microsoft Teams e armazenadas no sistema SAJ junto com a prova oral colhida em audiência.

Na sequência, pelo(a) MM(a). Juiz(a), foi proferida a seguinte sentença:

"Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público contra EMERSON LUAN BORGES, qualificado. Narrou a denúncia que, no dia 09 de março de 2021, por volta das 08h50min, na Rua Ambrosio Margutti, altura do nº 70, nesta cidade, o acusado vendeu e trazia consigo (para fins de tráfico), 23 porções de cocaína, com peso aproximado de 4,77 gramas, substância causadora de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Pugnou, assim, pela condenação às sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 49/52).

Notificado, em defesa prévia, sem preliminares, o acusado requereu a rejeição da denúncia. Arrolou testemunhas (fls. 120/121).

A denúncia foi recebida em 21/07/21, designando-se audiência de instrução (fl. 144).

Em audiência, foram ouvidas 2 (duas) testemunhas e interrogado o acusado.

Na fase do art. 402 do CPP, nenhuma diligência foi requerida.

Por meio de memoriais, o Ministério Público reiterou os termos da inicial acusatória e requereu a condenação do acusado.

A seu turno, a Defesa pugnou pela absolvição.

É o relatório. Fundamento e decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Inexistindo nulidades a inquinar o feito, e estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, examino o mérito.

A materialidade dos fatos promana do auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), boletim de ocorrência (fls. 08/10), auto de exibição e apreensão (fl. 11/12), auto de constatação preliminar (fl. 13/14), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 138/143), bem como da prova oral colhida.

A autoria é certa e deve ser atribuída ao acusado, o qual a confessou.

Com efeito, o militar Marcio Costa Rodrigues, em juízo, confirmando o depoimento

prestado no inquérito, informou que, ao passar pela confluência da Rua Ambrósio Margutti e Rua Dona Alexandra, Vila Cruz, nesta cidade, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, avistaram um sujeito identificado com EMERSON LUAN BORGES em atitude suspeita, ou seja, vislumbraram o indiciado entregar algo para uma mulher e receber dinheiro em troca; EMERSON é muito conhecido, nos meios policiais, pelo tráfico de entorpecentes e por esse motivo, imediatamente, abordaram EMERSON e a citada mulher, identificada como Valquíria Rissi; em revista pessoal com Valquíria foi encontrada uma (01) pedra de crack, pesando 0,02 grama; os ser questionada, acerca dos fatos, Valquíria confirmou ser usuário de drogas e que comprou aludido entorpecente de EMERSON; com este, em uma de suas mãos encontraram vinte e duas (22) pedras da mesma substância encontrada na posse de Valquíria, isto é, crack, com peso bruto de 4,75 gramas, e durante busca pessoal encontrou no bolso da bermuda de EMERSON a quantia de R\$ 39,00 (trinta e nove reais) em dinheiro trocado, bem como um aparelho celular; questionado pelo depoente, o denunciado admitiu estar traficando drogas e que o dinheiro apreendido é proveniente da venda de entorpecentes; já conhecia o acusado por tráfico; ele não aparentava estar drogado; nenhum objeto para consumo de drogas foi achado. A testemunha Lucas Francisquelli Gonçalo, também policial, sob o crivo do contraditório, ratificou o aduzido pelo colega de farda, depondo em semelhante sentido.

Nada nos autos aponta no sentido de que os depoentes tiveram o intuito espúrio de incriminar o agente indevidamente, o que não decorre de forma automática da condição de policial militar das testemunhas. Até porque prestaram depoimento sob o compromisso do art. 203 do CPP, razão pela qual o quanto por eles aduzido merece relevo para fins de formação do convencimento decisório. A jurisprudência é pacífica sobre o tema:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação policial, age facciosamente, ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.” (STF, HC 74.608-0/SP, Min. Celso de Mello, j. 18.2.97, apud JTJ 263/518)

As drogas não se destinavam ao exclusivo consumo pessoal. É o que defluiu da análise em concreto dos parâmetros estabelecidos pelo art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06. Afinal, o acusado confessou a prática do delito e os policiais presenciaram a venda de entorpecentes praticado pelo increpado, o qual foi confirmado pela consumidora. Além disso, como apurado ao longo da instrução, tais se encontravam acondicionados em pequenas porções, individualmente embaladas. Não bastasse, foi apreendido dinheiro trocado, circunstância típica do comércio espúrio de entorpecentes, em que o troco se faz necessário. Por derradeiro, o indivíduo não estava drogado, como um mero consumidor ali presente, até porque nenhum objeto destinado o uso foi encontrado. Tudo isso, reflete o propósito de difusão ilícita, o qual não é excluído, por si só, pela eventual concomitante condição de usuário regular de drogas.

Bem por isso, ficou claro que o denunciado, de forma consciente e intencional e, portanto, dolosa (art. 18, I, CP), vendeu e trouxe consigo drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O fato, pois, é típico, por se amoldar à conduta descrita no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

A ilicitude é patente, à luz da teoria indiciária ou da ratio cognoscendi, porquanto não há quaisquer eximentes.

Também se faz presente a culpabilidade. Isso porque o réu é imputável, tinha potencial consciência da ilicitude e dele era exigível conduta diversa, nenhuma dirimente militando em seu favor.

Nesse cenário, observada a harmonia e a coesão do conjunto probatório, não há

qualquer incongruência ou dúvida relevante que pudesse atrair a incidência do in dubio pro reo, corolário do princípio da presunção de inocência (art. 5º, XLVI, CF/88).

Destarte, sendo o fato típico, ilícito e culpável, de rigor a condenação.

II.1 – DOSIMETRIA DAS PENAS

Passo, pois, à dosimetria e individualização das penas (art. 5º, XLVI, CF/88), norteando-me, precipuamente, pelos arts. 59 e 68 do CP e art. 42 da Lei 11.343/06. A culpabilidade, assim entendido o grau de reprovabilidade, é normal à espécie.

Bons antecedentes. A conduta social, caracterizada pelo comportamento no meio em que vive, a personalidade, que representa a índole do agente, e os motivos, consubstanciados pelas razões delitivas, não contam com elementos suficientes para esclarecimento. As circunstâncias, dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, não integrantes de sua estrutura, que abrangem a natureza e a quantidade das drogas, serão sopesadas na terceira fase da dosimetria, para evitar o bis in idem. As consequências, as quais correspondem ao mal causado pelo delito que transcende o resultado típico, não foram graves. O comportamento da vítima, toda a coletividade, é neutro e não o desfavorece.

Na primeira fase, nenhuma circunstância valorada negativamente, fixo as penas-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, presentes a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, CP) e a agravante do art. 61, II, “j”, CP (calamidade pública), as compenso e mantenho as reprimendas.

O delito foi cometido em ocasião de estado de calamidade pública, conforme Decreto Legislativo n. 6 do Congresso Nacional e Decreto n.º 64.879 do Estado de São Paulo, ambos em vigor em 20.03.20, e que permanecem vigentes até o presente momento.

Trata-se de circunstância objetiva, cuja incidência deve se dar em razão da maior vulnerabilidade da saúde pública que, nem mesmo assim, foi óbice para que o réu cometesse o delito. Não se pode olvidar que a presente causa de exasperação da pena não se justifica apenas na hipótese em que o agente se vale da calamidade para praticar o delito. Ora, tal tem lugar, outrossim, em razão da maior reprovabilidade do fato praticado em meio ao caos sanitário provocado pela COVID-19, em que os recursos e esforços estatais devem ser focados no combate à pandemia – e não na persecução penal de delinquentes – em prol da preservação da vida e da saúde da população, bens jurídicos dos mais caros à proteção a ser conferida pelo Direito Penal. Nessa linha: TJSP; Apelação Criminal 1510850-88.2020.8.26.0050; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 27ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/02/2021; Data de Registro: 03/02/2021.

Na terceira fase, reconheço a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 e, não havendo majorantes, reduzo as penas em 1/3, concretizando-as em 3 (três) anos, 4 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Trata-se de agente primário, de bons antecedentes, que não se dedica a atividades criminosas, tampouco integra organização criminosa. É o que se infere de seu histórico criminal (fls. 161/164). Considerando que não ostenta nenhuma passagem policial prévia, mas que a traficância envolveu cocaína, droga cuja natureza ostenta alto potencial lesivo à saúde, embora apreendida em quantidade reduzida (4,77g), emprego, em proporção intermediária, a fração redutora de 1/3 para a causa de diminuição de pena em apreço.

Fixo o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo vigente ao tempo do fato, tendo em conta a ausência de informações sobre a condição econômica do réu (art. 49, § 1º c/c art. 60, CP).

O regime inicial será aberto, ante o patamar de pena corporal aplicado (art. 33, § 2º, “c”, CP).

Embora trate-se de crime equiparado ao hediondo, o art. 2º, § 1º da Lei 8.072/90, afigura-se inconstitucional, por desrespeito ao dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF) e ao princípio da individualização das penas (art. 5º, XLVI, CF) (HC 111.840, STF).

Inaplicável o art. 387, § 2º, do CPP, por ter o réu respondido o processo em liberdade.

Considerando o quantum de pena aplicado e as circunstâncias judiciais, em sua maioria favoráveis, concedo, com supedâneo no art. 44 do CP, a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, por igual período da condenação, à razão de 1 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, de acordo com as aptidões condenado e de forma a não prejudicar a sua jornada normal de trabalho, observando-se finalmente para o cumprimento da pena substitutiva, o disposto no § 4º do artigo 46 do Código Penal, e prestação pecuniária, no importe de 10 (dez) salários-mínimos, cuja destinação será definida na execução.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo procedente o pedido constante da exordial, resolvendo o mérito, para CONDENAR o réu EMERSON LUAN BORGES, qualificado nos autos, com fulcro no art. 387 do CPP, pela prática do crime previsto no art. 33, caput e § 4º, da Lei 11.343/06, a 3 (três) anos, 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, substituída a pena corporal por 2 (duas) restritivas de direitos, nomeadamente, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 10 (dez) salários-mínimos, nos termos da fundamentação retro, fixados unitariamente no mínimo legal.

IV - DELIBERAÇÕES FINAIS

Deixo de fixar valor mínimo para reparação do dano causado pela infração, na forma do art. 387, IV, do CPP, ao passo que não houve requerimento por parte do Ministério Público, o que inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado (art. 5º, LV, CF/88).

Defiro o recurso em liberdade, ao passo que desnecessária a segregação cautelar, à luz dos art. 282 c/c art. 312 c/c art. 313 c/c art. 387, §1º, do CPP.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais (art. 804, CPP). Eventual requerimento de gratuidade da justiça será analisado na fase de execução.

Após o trânsito em julgado: a) oficie-se ao Instituto de Identificação, na forma da lei; b) oficie-se ao TRE, para fins do disposto no art. 15, III, da CF/88 c/c art. 71 do Código Eleitoral; c) expeça-se guia de execução definitiva (art. 106, LEP); d) determino a destruição das amostras de drogas guardadas para contraprova, com certificação nos autos (art. 72, Lei 11.343/06); e) decreto o perdimento da quantia em dinheiro apreendida, enquanto produto do crime (art. 91, II, "b", CP c/c art. 122, CPP); f) a restituição do celular apreendido dependerá de requerimento específico, seguido de manifestação do Ministério Público, em conformidade com o art. 120 do CPP; g) oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Dispensado o registro (Provimento CG n. 27/2016)."

A sentença foi lida aos presentes que saíram devidamente intimados. Pela(o)(s) ré(u)(s) e pelo(a)(s) o(a)(s) Advogado(a)(s) de Defesa foi(ram) interposto(s) recurso(s) de apelação, neste ato, recebido(s) pelo(a) MM(a). Juiz(a), saindo a(s) Defesa(s) intimada(s) para apresentar(em) razões no prazo legal. Após, intime-se o Ministério Público para apresentar as contrarrazões do recurso, no prazo legal. Ao final, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as cautelas necessárias e homenagens deste juízo. O Ministério Público manifestou desejo de não recorrer, operando-se o trânsito em julgado para a acusação nesta data, valendo a presente como certidão.

Não havendo óbice na utilização de sistema de videoconferência em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados por esse sistema e juntados aos autos no sistema SAJ. NADA MAIS, para constar lavrei o presente termo de audiência. Dispensada a assinatura das partes por se tratar de processo eletrônico. Eu THAUANN PINHEIRO SANTIAGO, Escrevente Técnico Judiciário, M373043, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE, NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA